

第3問

甲は乙に対して、報酬を支払うことを約束して、Aを殺すように依頼した。そこで、乙は、ある夜Aを殺そうとして待ち伏せしていたが、まわりが暗かったために、BをAだと思い、ピストルを発射してBを殺してしまった。

甲及び乙の罪責を論じなさい。

第1 乙の罪責

具体的事実の錯誤のうち、客体の錯誤が問題となる事例である
(**論点** 具体的事実の錯誤  司H30,予H24,旧H5-2,H14-1)。

 総合 37 頁  論証 7 頁

判例(最判昭53.7.28【百選 I 42】)は、「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りるものと解すべきである……から、人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合にも、右の結果について殺人の故意があるものというべきである。」として、法定的符合説の立場に立つ。この立場から故意を阻却しないのは当然である。

もっとも、具体的符合説の立場からも、本問のような、客体の錯誤の事例では故意を阻却しないと解されている。

第2 甲の罪責

共犯についても、単独犯と同様の錯誤論が適用されると解する立場が一般的である。法定的符合説によれば、甲の故意も阻却されることはない(**論点** 共犯と錯誤～狭義の共犯)。

 総合 153 頁  論証 62 頁

答案構成

第1 乙の罪責について

1 殺人罪（199）の成否

↓

故意（38 I）の成否

↓

2 具体的事実の錯誤

↓

法定的符合説

↓

3 あてはめ

↓

乙は殺人罪の罪責を負う

第2 甲の罪責について

1 殺人罪の教唆犯（61 I）の成否

↓

故意の成否

↓

2 具体的事実の錯誤

↓

法定的符合説

↓

3 あてはめ

↓

甲は、殺人罪の教唆犯の罪責を負う

第1 乙の罪責について

1 乙は、殺意をもってピストルでBを射殺しているので、「人を殺した」として、殺人罪（199条）の罪責を負う可能性がある。

上記行為は、殺人罪の客観的構成要件に該当する。

しかし、乙はBをAと誤信して殺害しており、故意（38条1項本文）が阻却されるのではないか。

2 故意責任の本質は犯罪事実の認識によって反対動機が形成できるのに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。

そして、犯罪事實は、刑法上構成要件として類型化されており、かつ、各構成要件の文言上、具体的な法益主体の認識までは要求されていないと解されるから、認識した内容と発生した事実がおおよそ構成要件の範囲内で符合していれば犯罪事実の認識があったと考えられ、故意が認められると考える。

3 本問では、乙はAという「人」を殺害するつもりで、Bという「人」を殺害しているにすぎないから、同一構成要件内で主観と客観が一致している。

したがって、乙の故意は阻却されない。

以上から、乙は殺人罪の罪責を負う。

第2 甲の罪責について

1 甲は乙に対してAを殺害するよう依頼し、Aを殺害させている。そのため、甲は乙を「教唆して」殺人罪（199条）を「実行させた」として、教唆犯（61条1項）の罪責を負う可能性がある。

1

しかし、実際に乙が殺害したのはBであり、甲の依頼と異なる結果が生じている。

そのため、甲には同罪の故意（38条1項）が認められないのではないか。

2 前述のように構成要件の範囲内で主観と客観が一致していれば故意責任を問い得る。

3 本問においては、甲の主観と正犯者である乙が実行した結果はともに「人」という構成要件の範囲内で一致しているので、甲には故意が認められる。

以上から、甲は殺人罪の教唆犯の罪責を負う。

以 上

2